

1501968-96.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... RT 558/310)." e

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína em poder do réu - Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem - Negativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501968-96.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501968-96.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194069/2022 - DEL.POL.SALTO, 26194247 - DEL.POL.SALTO, 2194069 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVARENGA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu LEANDRO ALVARENGA BARBOSA, como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 13h26min, na Rua Bofete, nº 55, apto. 503, bloco 01, Jardim da Cidade IV, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 130 (cento e trinta) microtubos de "cocaína", com peso líquido de 86,20g (oitenta e seis gramas e vinte centigramas); b) 04 (quatro) microtubos de "cocaína", com peso líquido de 1,41g (um grama e quarenta e um centigramas) e c) 03 (três) porções de "maconha", com peso líquido de 3,88g (três gramas e oitenta e oito centigramas), tudo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 62-64).

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2022 (fls. 67-68). Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls.07-09), auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de constatação preliminar (fl. 12) e laudo de exame químico toxicológico (fls.54-56), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os policiais militares Rogério Marcelino da Cunha e Lyncoln Francisco Vieira Barros da Rosa, testemunhas comuns, foram uníssonos ao relatar em juízo que receberam denúncia anônima para averiguar uma grande quantidade de drogas no endereço Rua Bofete, 55, Bloco 1, Ap 503, para lá se dirigiram e ao chegarem no local bateram na porta e foram recepcionados por Leandro. Questionado se havia droga em seu apartamento, de imediato confessou que possuía drogas, tendo então franqueado a entrada. O réu indicou o local onde estariam as drogas, num guarda-roupas em seu dormitório onde foi encontrado um saco plástico contendo em seu interior 130 microtubos translúcidos e incolores com substância aparentando ser cocaína e mais 04 microtubos com a mesma substância, além da quantia de R\$ 1.300 (mil e trezentos reais) em dinheiro. Na sala de estar, foi encontrado ainda 03 porções de substância aparentando ser maconha sobre uma mesa. Em revista pessoal, com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro.

O réu, Leandro Alvarenga Barbosa, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que Os policiais militares apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que, após receberam denúncia anônima acerca da traficância realizada no endereço Rua Bofete, 55, Bloco 1, Ap 503, deslocaram-se até o local indicado, sendo recebidos pelo réu que admitiu que possuía drogas no seu imóvel e franqueou a entrada dos policiais militares. Foram localizadas, no interior de um guarda-roupas, um saco plástico contendo 134 microtubos de "cocaína", com peso líquido de 87,61g além da quantia de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e, na sala de estar, 03 (três) porções de "maconha" com peso líquido de 3,88g, todos embalados e prontas para comercialização.

As declarações de policiais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

As circunstâncias da prisão, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes dos apreendidos, em conformidade à denúncia anônima, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde foram apreendidas as drogas, afinal os entorpecentes foram apreendidos no interior da residência do acusado, não restando demonstrado que a localização das drogas tinha por objetivo alcançar as pessoas que frequentam instituto de ensino e centro esportivo próximo da casa. Além disso, o crime foi praticado em período de férias escolares, havendo presunção de ausência de fluxo de estudantes no prédio.

A respeito do tema, Renato Marcão in Tóxicos - Lei n. 11.343, de 23 de agosto de

2006 Lei de drogas anotada e interpretada (2014; p. 202) afirma:

"É necessário que com a prática ilícita o agente vise qualquer dos locais listados no inciso III do art. 40, cuja incidência reclama um agir dolosamente (ainda que eventual); requer a finalidade de alcançar as pessoas que frequentam qualquer daqueles locais determinados."

Ainda, nesse sentido, já julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A causa de aumento de pena somente tem lugar quando o agente nos locais ali especificados se encontrar com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu torpe comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes ou presidiários. (TJSP, Ap. 5.803-3, 2ª Câ., rel. Des. Rezende Junqueira, j. 16-3-1981, RT 558/310)." e

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína em poder do réu - Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas - Condenação mantida - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes - Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida - Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma norma - Não comprovada a existência de estabelecimento de ensino e de recreação nas proximidades do local dos fatos - Crime praticado em período de férias escolares e de suspensão das aulas presenciais, havendo presunção da completa desocupação do prédio - Inexistência de prova em sentido contrário, de incumbência do órgão acusador - Pena ajustada - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a recalcitrância criminal - Impossibilidade da modificação do regime prisional com base no período de prisão preventiva - Questão que deve ser analisada pelo Juízo da execução - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15009962620218260603 SP 1500996-26.2021.8.26.0603, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/02/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

Finalmente, o Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, sem prova de que integre associação criminosa, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida não justifica o afastamento do redutor: 134 microtubos de "cocaína", com peso líquido de 87,61g e 03 (três) porções de "maconha" com peso líquido de 3,88g, o réu é primário (fls. 20-21) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de policiais militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Na mesma linha de entendimento, observada a quantidade apreendida:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por

violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021). (grifei)

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. No mais, os atos infracionais não autorizam o afastamento do redutor, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. 4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202574 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e

valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento da quantia de R\$ 1.326,00 (mil e trezentos e vinte e seis reais) pertencente ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, tem-se que a droga apreendida (cocaína) é de maior poder vulnerante, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, presente a atenuante da confissão, que não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, sem agravantes.

Não há outras circunstâncias a serem avaliadas na aplicação da pena.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias em que se deu a prisão e sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LEANDRO ALVARENGA BARBOSA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento do valor em dinheiro pertencente ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006)

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA